Processo nº **0149723-56.2023.8.17.2001**

AUTOR(A): MILLENA MARIA MONTEIRO

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA

Vistos etc.,

MILLENA MARIA MONTEIRO, devidamente qualificada na inicial, por meio de seus advogados, ingressou com a presente **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA** contra **SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE**, igualmente qualificado nos autos, objetivando em sede de tutela antecipada que o réu autorize e custei de forma integral e imediata com o tratamento prescrito em favor da parte Autora, **o medicamento VERZENIOS (ABEMACICLEBE)**, nos termos da indicação médica acostada.

Aduz que foi diagnosticado com "carcinoma lobular invasivo", também chamado de câncer de mama lobular, em dezembro de 2022, e que o tratamento de Quimioterapia oral com **VERZENIOS (ABEMACICLEBE)** teria sido indicado pelo médico assistente, com urgência – id.153248584.

Ao solicitar a autorização da cobertura do medicamento VERZENIOS (ABEMACICLEBE), a Autora recebeu a negativa da Ré em 30/10/2023, sob a justificativa de que se trataria de

medicamento de uso *OFF LABEL*.

Requereu liminarmente que a parte ré seja compelida a custear a todo o tratamento de câncer da Requerente, incluindo o medicamento VERZENIOS (ABEMACICLEBE), sob pena de multa diária. No mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada, a restituição do valor de R$ 1.690,00 pelo pagamento do exame genético e indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

Juntou documentos de id. 153247056 a 153248589.

Liminar deferida – ID nº 157556153.

Contestação com documentos – ID nº 163441341, sem preliminares, alegando, em síntese que a parte autora contratou o seguro de saúde e anuiu com os termos da proposta, defende que inexiste previsão legal para fornecimento de medicamento **VERZENIOS (ABEMACICLEBE)**, pois estaria fora do rol da ANS. Salienta que o medicamento prescrito é considerado OFF LABEL (cuja indicação do médico diverge do que consta na bula), sendo, portando, tratamento experimental, sem comprovação científica.

Malote digital de id. 174071568, informando o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao recurso da ré, mantendo a liminar em todos os seus termos, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0004262-71.2024.8.17.9000, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho.

Réplica à contestação – ID nº 175305041.

Devidamente intimadas, as partes não pleitearam a produção de outras provas.

Os autos vieram conclusos para decisão.

É o breve relato. Passo a decidir.

Afirmada a necessidade da demandante, e à míngua de informações em contrário, defiro o benefício da justiça gratuita (art. 98 do CPC).

O feito se apresenta suficientemente instruído e comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC, por não haver necessidade de dilação probatória.

Cogente dizer que é aplicável ao caso *subjudice* às normas constantes no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma típica relação de consumo, conforme preceitua o Art.2° e 3° do CDC.

Segundo a Súmula 608: **"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."**

Neste norte, o motivo que ensejou o ajuizamento da presente demanda reside na negativa da Ré em autorizar o tratamento solicitado pelo médico, conforme prescrição médica, sob a justificativa de que o tratamento solicitado é experimental e não é recomendado para a patologia do segurado, segundo a bula ANVISA.

Observe-se que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 35 da Lei n° 9.656/98, porquanto envolvem nítida relação de consumo.

Nesse contexto, incide a norma do art. 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favoráveis ao consumidor.

O Código considera abusiva - e, portanto, sem efeito - toda cláusula que exclui a cobertura de procedimentos necessários à assistência à saúde do usuário.

"Ainda que houvesse cláusula expressa prevendo a exclusão de cobertura para procedimentos e/ou tratamentos não previstos no rol da ANS, seria nula de pleno direito, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor: "Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (.) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".

Afirma-se isso porque tal cláusula implicaria em se suprimir procedimentos que podem ser mais adequados ao controle ou cura da enfermidade, desnaturando o próprio objetivo do contrato de prestação de serviço de saúde.

Além disso, considerando o quadro clínico do consumidor, e diante da justificativa médica apresentada ao caso, restando nítida a necessidade de tratamento, a conduta abusiva e atentatória contra o princípio da dignidade da pessoa humana. **(https://www.migalhas.com.br/depeso/266410/plano-de-saude-nao-pode-negar-ratamento-prescrito-por-medico)**

De forma que da análise do conjunto probatório verifico que **a pretensão merecer prosperar.**

A teor da mais recente jurisprudência, para exame de possibilidade da cobertura do plano de saúde **deve ser considerada a existência de previsão dessa (cobertura) para a patologia e não o tipo de tratamento a ser empregado.**

Não ignoro o que dita a respeito do assunto a Lei dos Planos e Seguros Privados de Saúde (Lei nº 9.656/98, art. 10, inc. VI), mas merece registro também aqui o que já foi dito inclusive

pelo STJ ((REsp 668216/SP, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, em 15.03.2007), **no sentido de que não cabe à operadora do plano de saúde determinar qual tratamento médico deve ser ministrado no combate à determinada doença, pois essa é prerrogativa que pertence ao médico assistente do segurado.**

Não vinga, entretanto, a justificativa, ao menos de molde a afastar o direito da parte Autora à cobertura pretendida.

Primeiro, a operadora do plano de saúde não detém mais autoridade do que o médico do segurado para estabelecer qual o melhor tratamento a que esse deve ser submetido, ou o medicamento que lhe deve ser ministrado, em continuidade ao tratamento principal, no sentido de tratar as enfermidades secundárias.

O profissional médico que trata a parte autora, fez a indicação do tratamento que reputa adequado a sua situação de saúde.

E isso é o que importa e deve ser atendido.

No caso então importa a previsão de cobertura da doença e não de um tratamento específico.

Terceiro, por se tratar de relação de consumo, nos termos do Art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e em se tratando de contrato de adesão, as cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, a teor do que preceitua o Art. 47 desse diploma legal.

Não há como então estagnar a cobertura contratual para o combate e uma doença que está prevista, em face de regras que já se afastam agora da atualidade no seu tratamento.

É de reiterar que no sentido do supra exposto, ou seja, de que o plano de saúde pode estabelecer quais as doenças que serão cobertas, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser alcançado ao paciente, existe jurisprudência já assentada:

> *DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA AGRESSIVA. TUMOR CEREBRAL. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA E TERAPIA MEDICAMENTOSA COM TEMODAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO NA INSTÂNCIA INFERIOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. 1. Assegurada a cobertura para a patologia, a técnica médica que se destina a curá-la ou controlá-la, por decorrência lógica e jurídica, deve ser igualmente coberta. 2. O STJ afastou do conceito de tratamento experimental as indicações diversas das descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label) - REsp Nº 1.769.557/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi. 3. Tendo em vista a prescrição fundamentada do médico assistente de internação hospitalar do autor em UTI pediátrica para dar continuidade à terapia medicamentosa, não se mostra legítima a recusa de cobertura baseada em uso off label de medicamento, notadamente porque o medicamento (TEMODAL) tem registro da ANVISA (Registro ANVISA nº 101710194[1]), a temozolomida é medicamento antineoplásico indicado para o tratamento de tumores do sistema nervoso, doença que acomete o autor, bem como não há qualquer elemento de convicção no sentido de que o tratamento indicado não tem o apoio da comunidade científica ou põe em risco à saúde do consumidor. 3. A negativa abusiva de cobertura contratual do tratamento para neoplasia é suficiente para agravar a angústia, a insegurança, a aflição e a dor psíquica das quais inexoravelmente já se acham acometidos o paciente e seus familiares próximos. Noutras palavras, com a recusa da cobertura, o paciente e seus familiares, já desgastados, aflitos e inseguros quanto aos desdobramentos da doença e à eficácia, dor e efeitos colaterais dos tratamentos ambulatoriais ou cirúrgicos, veem-se inesperadamente desamparados por aquele que foi contratado e remunerado, muitas vezes durante anos, exatamente para ampará-los*

naquelas circunstâncias. E nesse contexto, as preocupações, inicialmente centradas nas decisões de cunho médico, passam a dividir espaço com novas angústias, desta vez relacionadas aos aspectos financeiros e burocráticos referentes ao tratamento. 4. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. considerando os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC/15 (art. 20, § 3º do CPC/73), quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, razoável a fixação dos honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação. 6. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 11079-41.2020.8.17.2001, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator [1] https://www.smerp.com.br/anvisa/?ac=prodDetailanvisaId=101710194 *(https://www.smerp.com.br/anvisa/?ac=prodDetailanvisaId=101710194) (TJ-PE - AC: 00110794120208172001, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 29/07/2022, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))*

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. Relação contratual caracterizada. Medicamentos necessários para o tratamento. Paciente diagnosticado com carcinoma hepatocelular. Antineoplásicos atezolizumabe"e"bevacizumabe. Enquadramento na exceção prevista para medicamento off label, segundo entendimento do C. STJ. Ingerência na ciência médica pela operadora do plano de saúde. Recusa

abusiva. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10071342820238260011 São Paulo, Relator: Lia Porto, Data de Julgamento: 10/08/2023, Data de Publicação: 10/08/2023)

CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DO COLO DO ÚTERO. USO DE PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO. NEGATIVA INDEVIDA. ABUSIVIDADE.DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A recomendação para a utilização do medicamento é do profissional que detém o conhecimento técnico sobre o melhor tratamento a ser adotado, não cabendo às operadoras substituírem os técnicos neste mister, sob pena de se pôr em risco a vida do consumidor. 2. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, devendo apenas ser registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente. 3. É abusivo o ato que negou à consumidora o direito a ter o medicamento antineoplásico indicado pelo seu médico assistente, devendo o plano de saúde indenizar em danos morais. 4. Considerando a função educativo-punitiva da indenização por danos morais, a extensão do dano e as variáveis do caso concreto, é razoável a fixação da verba compensatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso não provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0032100-39.2021.8.17.2001, em que figura como Apelante Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico, e, como Apelada Suemi Kaneko Lindoso, acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator. Recife/PE, data da assinatura digital. SILVIO NEVES BAPTISTA FILHO Desembargador Relator (TJ-PE - AC:

00321003920218172001, Relator: JOAO JOSE ROCHA TARGINO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

Assim, se o médico da parte Autora entende ser o tratamento mais indicado para o paciente, não há justificativa para que operadora do plano de saúde negue a cobertura.

A ratificação da tutela antecipada concedida não vem a ser, apenas, medida de justiça, mas também, e principalmente, uma providência necessária à manutenção da vida, que é certamente o objetivo único pelo qual a parte autora associou-se à entidade demandada.

E negar a pretensão autoral é negar o próprio contrato sobre o qual se funda o pedido.

Não pode, portanto, o Réu fugir à responsabilidade de ter que arcar com uma necessidade básica com a qual se comprometeu ao celebrar um contrato de prestação de serviços médicos, retirando do associado a segurança contratual e necessária de um serviço vital.

Também na instância superior deste Estado a questão resta pacífica, conforme decisão consubstanciada na súmula 035, que reza:

"A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral".

Por estas razões, entendo abusiva a negativa de cobertura do tratamento, motivo pelo qual deve ser mantida a determinação imposta na decisão antecipatória.

DOS DANOS MORAIS

Pretende, também, a parte Autora ser ressarcida pelos danos morais de que foi vítima.

A recusa da parte Demandada em fornecer o medicamento em determinados casos tem repercussões no íntimo da vítima em níveis mais elevados.

A parte autora é pessoa enferma necessitando da medicação que lhe foi indicada a fim de melhorar sua qualidade de vida, tendo sido diagnosticado com “carcinoma lobular invasivo”, também chamado de câncer de mama lobular, pela mastologista Dra. Cinthya Roberta Santos de Jesus, CRM/PE 14833.

A recusa, então, atingiu sua estima em um momento em que mais precisaria de apoio, acarretando um claro prejuízo extrapatrimonial.

Ademais, "(...) A jurisprudência do STJ é no sentido de que, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. (AgRg no AREsp 723245/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 03.12.2015, DJe 11.12.2015).

Por isto, deverá a Demandada arcar com a lesão causada ao acervo imaterial da Demandante, considerando a surpresa tida pela recusa, e como forma, principalmente, de penalizar o ofensor, na medida de sua ofensa.

A fixação da indenização em **R$ 5.000,00** é razoável ante as circunstâncias.

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pela tabela do ENCOGE a partir desta data em que está sendo fixado e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação, já que se trata de responsabilidade contratual.

DOS DANOS MATERIAIS

Pretende, a parte autora, a restituição do valor de R$ 1.690,00 pelo pagamento do exame genético, o qual não foi autorizado pela ré – id.153247068.

Quanto ao pedido de reembolso, entendo que tal sorte logrou a parte autora, uma vez que, conforme se observa no laudo médico anexado – id. 153247066, o exame genético foi solicitado considerando o quadro da autora.

Dessa forma, comprovado a necessidade para a realização de exame, nos termos do art. 12, VI da Lei nº 9.656/98 e verificado nos autos a comprovação do pagamento faz jus a autora ao reembolso, conforme nota fiscal id.153247070.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e de tudo o que consta nos autos, com arrimo nos fundamentos fáticos e jurídicos ora explicitados, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolvo **JULGAR PROCEDENTES** as pretensões entabuladas na exordial, para:

a) **CONDENAR** a parte requerida ao pagamento de **1.690,00 (mil, seiscentos e noventa reais), referente ao valor pago pela Autora pelo exame genético**, para reparar os **danos materiais sofridos**, valor este a ser atualizado monetariamente de acordo com a Tabela ENCOGE desde o desembolso, sendo devidos também juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

b) DETERMINAR que a Réu **autorize e custei o tratamento da parte autora nos termos prescritos pelo médico**, qual seja, forneça o medicamento **VERZENIOS (ABEMACICLEBE)**, na quantidade exigida no Laudo e Guia Médico, podendo aumentar a dosagem de acordo com a prescrição médica, pelo tempo que for necessário, ao mesmo tempo em que confirmo a **TUTELA** concedida antecipadamente para os efeitos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC;

c) **CONDENAR** a ré ao pagamento de indenização por dano moral, na importância equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização pela tabela ENCOGE a partir desta Sentença (Súmula 362 STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Pela sucumbência, atento ao princípio da causalidade, **condeno** a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação com arrimo no Art.85, § 2º, I e IV do CPC.

No caso de interposição de apelação, determino a intimação da apelada para responder no prazo legal de 15(quinze) dias úteis e posteriormente decorrido esse prazo com ou sem resposta, encaminhe-se o processo ao Egrégio Tribunal de Justiça e/ou no caso do trânsito em julgado da sentença, aguarde-se o decurso do prazo de 15(quinze) dias úteis para promoção do pedido de cumprimento de sentença ou o cumprimento espontâneo, arquive-se o processo, observando-se as formalidades legais.

Alerto às partes que, ao opor-se a decisão deste juízo, atente às peculiaridades do feito e aos princípios processuais, pois a adoção de embargos de declaração com intuito protelatório poderá acarretar na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

P.R.I. e com o trânsito em julgado e decorrido o prazo acima assinalado para ajuizamento do cumprimento da sentença, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais.

Recife, data da assinatura.

Fernando Jorge Ribeiro Raposo

Juiz de Direito

R

Assinado eletronicamente por: FERNANDO JORGE RIBEIRO RAPOSO
06/09/2024 13:48:48
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 180963917

24090613484865400000176566378

IMPRIMIR GERAR PDF